陳奕先　11145241

刑法總則　作業一

第一題（107 年地方政府特考三等）

一、本題就甲撞死乙之行為，不成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．甲就乙之死亡結果並無知與欲，不成立故意殺人罪，故本題僅就過失犯之成立與否進行審查，本案甲若未駕車撞擊乙，乙即不會產生死亡之結果，因此兩者間應具備條件因果關係。

2．客觀注意義務之審查

（1）針對甲超速部分，係違反道路交通法規所具體化之注意義務，已然創造法所不容許之風險。

（2）又針對甲無照駕駛部分，駕照之創設係以行政管制確保駕駛者之基本駕駛能力為目的，題示並未顯示甲係因欠缺駕駛技術而肇事，因此無照駕駛不足以構成本件過失依據，僅生行政罰之問題。

（3）就信賴原則探討，參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守相關交通法令並盡相當之注意義務，始得信賴他人亦能遵守交通規則。本題甲自身超速在先，自不得主張信賴原則以排除其注意義務。

3．義務違反關聯性之審查

本題爭點係探討甲即使未超速，仍有「高度可能性」撞上乙時，此般遵守注意義務結果仍可能發生之情形，學說上有以下見解：

（1）風險升高理論：此學說認為若有違反注意義務行為，相比遵守時升高結果發生的機率，始具義務違反關聯性。然此說單純以機率之高低論斷，似有違罪疑唯輕原則，又恐有不當擴張過失犯處罰範圍之疑慮，因此本題不採納此學說。

（2）迴避可能性理論（本題採之）：此學說認為須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。若遵守注意義務時，結果仍確定發生，即屬客觀不可避免（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）；若結果僅係有可能發生，學者認為因無法確定遵守義務即能避免結果，應本於罪疑唯輕原則，作有利於行為人之認定，否定義務違反關聯性。

（3）據此，本題中甲即使未超速，仍具備高度可能性撞上乙而使其死亡結果發生，無法判斷甲遵守速限即可避免，因此乙的死亡在客觀上不可避免，欠缺結果不法，客觀上不可歸責於甲。

（二）競合與結論

綜上所述，乙之死亡既客觀上不可歸責於甲，且過失犯不處罰未遂，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，既無犯罪成立，自無競合問題。而甲無照駕駛及超速，僅生行政罰鍰之問題。

第二題（108 年司法人員特考三等）

一、本題就甲酒後駕車之行為，成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．客觀構成要件之審查

本罪係屬抽象危險犯，只要完成法定犯行即推定危險存在。本案甲吐氣所含酒精濃度為每公升 0.35 毫克，已然超過本款每公升 0.25 毫克之標準，又駕駛汽車上路，客觀構成要件應已該當。

2．主觀構成要件之審查

本題爭點係探討甲「自認」不致超標時，是否欠缺故意。參照刑法第 13 條第 2 項，行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。本案甲明知自己飲酒且有微酣感，友人亦當場勸阻，對於酒精濃度可能超標應已有所預見，其「應不致超標」之想法並無任何客觀依據，僅屬一廂情願之期待。依學說上之梗阻理論，行為人既可預見後果，原則上即推論其具備意欲，本題並無足以推翻之具體間接證據，因此甲應具備本罪之間接故意。

（二）違法性與罪責

本案甲並無阻卻違法事由，其酒精濃度亦不致使其辨識或控制能力喪失或顯著減低（刑法第 19 條），應具備罪責，故甲成立本罪。

二、本題就乙之死亡結果，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，亦不成立第 185 條之 3 第 2 項、第 3 項之致死罪，以下說明之：

（一）過失致死罪之審查

1．甲就乙之死亡並無知與欲，故僅就過失犯之成立與否進行審查，本案甲若未駕車行經該處，即不會與乙車對撞，因此兩者間應具備條件因果關係。

2．行為態樣之審查

針對甲未開啓車前大燈部分，形式上似屬不作為，然作為與不作為之區分，應從規範角度依刑法對行為人之期待決定。本案刑法所禁止者係「駕駛未開燈之車輛上路」此一積極舉止，因此甲之行為整體仍屬作為。

3．客觀注意義務之審查

針對甲酒後駕車且未開啓車前大燈部分，係違反交通法規所具體化之注意義務，已然創造法所不容許之風險。

4．義務違反關聯性之審查

本題爭點係探討乙自己超速失控越線，致兩車於「甲來不及反應之際」已然對撞時，乙之死亡是否仍可歸責於甲，以下分述之：

（1）酒駕規範所欲防止者，係駕駛人因酒精致反應能力下降而肇事之風險；未開大燈所欲防止者，則係他方無法辨識本車位置之風險。

（2）依迴避可能性理論，須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。本案甲即使未飲酒且已開啓大燈，面對突然越線之乙車仍無從閃避，屬於遵守注意義務時結果仍確定發生之情形，即屬客觀不可避免（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）。

（3）又乙之死亡係其自己以極度危險之駕駛方式所招致，屬被害人自主危險之範疇，應由乙自我負責。

（4）另依實務所採之相當因果關係說，遭對向失控車輛越線撞擊，並非酒駕行為通常會導致之結果，兩者間亦不具相當性。

（5）據此，乙的死亡在客觀上不可歸責於甲，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪。

（二）不能安全駕駛致死罪之審查

刑法第 185 條之 3 第 2 項及第 3 項（曾經緩起訴處分確定，十年內再犯）之致死罪，皆屬加重結果犯（刑法第 17 條）。參照最高法院 107 年度台上字第 1836 號判決，基本犯罪與加重結果間須具相當因果關係，且行為人對加重結果客觀上有預見可能性，始能成立。本案甲雖前經緩起訴處分確定，然乙之死亡既不可歸責於甲，兩者間亦不具相當因果關係，因此甲不成立該二項之罪。而甲自身重傷部分，刑法不處罰自傷行為，自無庸論罪。

三、競合與結論

綜上所述，甲僅有一個酒後駕車之行為，僅成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪一罪，自無競合之問題。

第三題（111 年公務人員高等考試三級考試）

一、本題就甲撞死 A 之行為，成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．甲就 A 之死亡並無知與欲，故僅就過失犯（刑法第 12 條第 2 項）之成立與否進行審查，本案甲若未駕車撞擊 A，A 即不會死亡，因此兩者間應具備條件因果關係。

2．客觀注意義務之審查

（1）針對甲超速部分，甲於速限 50 km/h 之市區道路以 80 km/h 行駛，係違反道路交通法規所具體化之注意義務，已然逾越容許風險，創造法所不容許之風險。

（2）就信賴原則探討，甲雖係綠燈通行而 A 闖紅燈，然參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守相關交通法令並盡相當之注意義務，始得信賴他人亦能遵守交通規則。本題甲自身超速在先，且超速正係其無法及時剎車之原因，自不得主張信賴原則。

（3）就客觀預見可能性探討，以理性謹慎之一般駕駛人為標準，於市區大幅超速通過路口恐剎車不及而撞擊他人，客觀上應可預見。

3．義務違反關聯性之審查

本題爭點係探討事後證明甲未超速即可及時剎車時，A 之死亡是否可歸責於甲，以下說明之：

（1）依迴避可能性理論，須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。本案甲若未超速即可及時剎車，屬於遵守注意義務時結果幾近確定不會發生之情形，因此應具備義務違反關聯性。

（2）又速限規定之保護目的，正係防止車速過快以致剎車不及而撞擊他人，A 之死亡屬於該規範保護目的範圍內之風險實現，客觀上可歸責於甲。

（3）另依實務所採之相當因果關係說，超速致剎車不及撞死他人，依一般經驗亦屬通常可能發生之結果，兩者間應具相當因果關係。

(二) 違法性與罪責

本案甲並無阻卻違法事由，又甲具完全責任能力，依其個人能力應可預見並避免結果，因此具備罪責。

(三) 競合與結論

綜上所述，甲僅有一個駕車撞擊之行為，成立刑法第 276 條過失致死罪一罪，自無想像競合或數罪併罰之問題。